

1501149-64.2021.8.26.0472

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JOANNA PALMIERI ABDALLAH

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... prévio do denunciado com a prática de tráfico ilícito de drogas.

A condição de usuário não exclui, necessariamente, a prática do crime de tráfico de drogas. Pelo contrário, a experiência mostra que é comum a traficância entre dependentes e usuários justamente para viabilizar o sustento do consumo próprio, sendo inviável o afastamento do dolo ou desclassificação do delito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

1ª Vara

R. Dr. Carlindo Valeriane, 525, Porto Ferreira - SP - cep 13660-017

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501149-64.2021.8.26.0472 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501149-64.2021.8.26.0472

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID BENEDITO GONCALVES DO ROSARIO

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOANNA PALMIERI ABDALLAH

Vistos.

DAVID BENEDITO GONÇALVES DO ROSÁRIO, qualificado à fl. 21, foi denunciado e está sendo processado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso na sanção do artigo 157, § 3º, inciso II do Código Penal e no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em concurso material de infrações.

Consta nos autos, que no dia 07 de outubro de 2021, por volta das 21h15min, na Rua Luiz Gama, nº 678, Centro, nesta cidade e comarca, DAVID BENEDITO GONÇALVES DO ROSÁRIO, vulgo R15, qualificado a fls.22, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra a vítima Renata Bellini dos Santos e de violência consistente em disparo de arma de fogo que atingiu a vítima Eliete Aparecida Rosini Ferracin Munhoz, uma motocicleta marca Yamaha modelo YBR 125K, Placa DHI4F02 pertencente a Renata Bellini dos Santos, sendo que que da violência empregada adveio a morte da vítima Eliete Aparecida Rosini Ferracin Munhoz. Consta, ainda, que no dia 08 de outubro de 2021, nesta cidade e comarca de Porto Ferreira, DAVID BENEDITO GONÇALVES DO ROSÁRIO, vulgo R15, já qualificado, guardava e trouxe consigo, para fins de tráfico, 712 porções de "cocaína" com peso bruto de 870,0 gramas, 53 porções de "crack" com peso bruto de 08 gramas e 216 porções de "maconha" com peso bruto de 765,0 grama, sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls.35/36 e laudos periciais de fls.66/69, 70/73, 74/77 e 83/86). Segundo foi apurado, o denunciado se dirigiu caminhando ao local dos fatos, atravessou a Rua Luiz Gama e abordou a vítima Renata quando ela estacionava sua motocicleta. Ato contínuo, o denunciado, mediante o emprego de grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, anunciou o assalto, tendo a vítima Renata apresentado resistência, razão pela qual DAVID efetuou um disparo para cima, conforme se verifica abaixo. Ao ouvir o disparo, a vítima Eliete abriu a porta do estabelecimento comercial para verificar o que estava acontecendo, ocasião em que o denunciado efetuou outro disparo em sua direção, atingindo-a na região torácica. Ato contínuo, o denunciado se evadiu do local na posse da motocicleta subtraída da vítima Renata. Apesar de socorrida, a vítima Eliete não resistiu ao ferimento e veio a óbito no hospital, em razão de hemorragia aguda advindo de trauma torácico por ferimento de arma de fogo (cf. laudo necroscópico de fls.78/82). A Polícia Civil iniciou as investigações, dirigiu-se ao local dos fatos e analisou as imagens das câmeras de segurança. Em seguida, os agentes públicos percorreram a cidade e traçaram prováveis rotas de fuga e locais em que a motocicleta poderia ter sido abandonada (cf. relatório de investigação de fls.43/65). No dia seguinte, foram cumpridas ordens de prisão preventiva contra três acusados por outro crime de roubo, ocorrido no dia 17 de agosto de 2021, na Rua Luiz Gama, nº 1.399 (mesmo logradouro) nos autos do processo nº 1501052-64.2021.8.26.0472 (fls. 204/205), dentre eles o denunciado (fls. 39/40). Após o cumprimento da ordem, a Autoridade Policial entrou em contato com a vítima Renata, a qual compareceu na Delegacia e reconheceu, sem qualquer dúvida, DAVID como sendo a pessoa que a havia abordado defronte ao estabelecimento e subtraído sua motocicleta (fls.17). O denunciado também foi reconhecido por Leonardo Vieira (fls.19 e 20). Na tarde do dia 8 de outubro de 2021, a Polícia Militar recebeu informação dando conta de que uma motocicleta havia sido abandonada em uma mata próximo ao bairro Porto Belo I, nesta cidade e comarca. Em diligência no local, os policiais constataram se tratar da motocicleta objeto do crime. Além do veículo, foram encontrados no local uma bolsa contendo as roupas utilizadas pelo denunciado, uma arma de fogo do tipo revólver calibre .38, uma faca, drogas e uma balança, conforme auto de exibição e apreensão de fls.35/36. Assim, a quantidade de drogas e o encontro de balança de precisão são suficientes para concluir que se tratavam de entorpecentes destinados à traficância. Outrossim, as circunstâncias apuradas pela Polícia Civil, em especial o encontro das drogas no mesmo local em que a arma de fogo, as roupas do denunciado e a motocicleta subtraída se encontravam; a localização do denunciado próximo ao referido local quando da realização de sua prisão preventiva; o envolvimento prévio do denunciado com a prática do tráfico ilícito de drogas, demonstram, com segurança, que as drogas encontradas também pertenciam a DAVID, que providenciou o abandono das drogas, da arma e da motocicleta subtraída visando desvinculá-lo das atividades ilícitas graves investigadas pela Polícia. A arma foi submetida a exame pericial (fls. 101/103), encontrando-se apta para efetuar disparos e com resultado positivo em relação ao uso recente de disparo. Urge ressaltar, mais uma vez, que os objetos foram encontrados próximos ao local da captura do denunciado no dia 08 de outubro de 2021, conforme indicado à fl. 63. A motocicleta foi restituída à vítima Renata (cf. auto de fl. 37).

A denúncia de fls. 134/138, foi recebida em 09 de dezembro de 2021(fl. 138).

Manifestou-se o Ministério Público (fls.129/130) pela decretação da prisão preventiva do réu.

Foi decretada a prisão preventiva dos réus (fls. 123/130).

Mandados de Prisão Cumpridos em 13 de dezembro de 2021.

Citado (fl. 171) o réu apresentou resposta à acusação (fls. 254/258). Sustenta que os fatos ocorreram de forma diversa à narrada na peça acusatória, o que provarão durante a instrução.

Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima, as testemunhas de acusação, e, ao final, os réus foram interrogados.

Em sede de alegações finais, o douto representante do Ministério Público postulou pela condenação dos acusados.

Por sua vez, em derradeiras alegações, a Defesa postulou pela absolvição dos acusados.

Relatados.

Fundamento e decido.

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade está demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 04/07 e fls. 39/40), auto de exibição/apreensão (fls. 65/67), relatório médico (fl. 08), fotografia da vítima (fls. 13/14), fotografia da droga, faca e arma de fogo apreendidas (fl. 60), auto de entrega (fl. 38), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 15,17,19), auto de exibição e apreensão (fls. 35/37), laudos periciais (fls. 66/103), relatório de investigação (fls. 43/65), bem como pelo relatório final elaborado pela autoridade policial (fls. 113/120).

Outrossim, a autoria do réu ficou comprovada de forma segura, estreme de dúvidas, tendo a vítima reconhecido o acusado na fase policial como se comprova pelo depoimento da vítima ouvida em Juízo. Vejamos:

A vítima RENATA BELLINI DOS SANTOS, em seu depoimento em solo policial, disse que sobre os fatos a declarante relata que trabalha como entregadora na empresa DELICIA AÇAI; que na data de ontem, por volta das 21:15, estava encerrando seu turno de trabalho, e no instante que montou em sua motocicleta para ir embora, uma rapaz desconhecido, exibindo uma arma de fogo tipo revólver de cor preta, aproximou-se anunciando que tratava-se de um assalto, sendo certo que o indivíduo queria roubar sua motocicleta; que de imediato, no reflexo, acabou resistindo em sair da motocicleta, tendo o rapaz, efetuado um disparo para o alto; que, a declarante praticou tal ato pois já teve esta moto furtada anteriormente, a qual foi achada momentos depois pois a chave não estava no contato; que ato contínuo a declarante desceu da motocicleta, sendo empurrado pelo indivíduo, sendo que, após isso ele efetuou outro disparo na direção da porta do Estabelecimento Comercial; que o disparo acertou o pescoço de sua patroa ELIETE APARECIDA FERRACIN MUNHOZ, a qual veio a óbito ali mesmo no local; que tentaram socorrer-la, mas sem êxito; que nesta data a declarante foi convidada por Policiais Civis a comparecer nesta Delegacia de Polícia, para fins de observar a fotografia de pessoas suspeitas; que ao ver a foto DAVID APARECIDO GONÇALVES DO ROSÁRIO Vulgo "R15", a declarante informa que o reconhece sem sombra de dúvidas como sendo o autor do fato; que viu bem o rosto de tal pessoa, uma vez que o mesmo não se preocupou em cobrir o rosto; que não conhecia tal pessoa sendo certo que jamais tinha o visto; que sua motocicleta de placa DHI-4F02, foi roubada e até o presente momento não foi recuperada, estando a mesma avaliada em R\$ 4.000,00; que, a declarante não sofreu qualquer dano a sua integridade física e nada mais foi levado além da motocicleta.

Em juízo, declarou que estava encerrando seu turno de trabalho, e no instante em que montou em sua motocicleta para ir embora, um rapaz desconhecido, exibindo uma arma de fogo, anunciou o assalto e pediu o capacete. Que se negou a dar o capacete e em razão disso o réu efetuou um disparo para o alto e a empurrou. Que posteriormente o réu montou na motocicleta e quando estava prestes a empreender fuga sua patroa Eliete tendo ouvido o disparo da arma de fogo saiu para ver o que estava acontecendo. Que nesse momento o réu disparou contra a vítima Eliete, a qual veio a óbito ali mesmo no local. Que depois disso, o réu fugiu em posse da motocicleta. Que a motocicleta foi encontrada 02 (dois) dias depois do ocorrido. Que não teve dúvidas quanto a autoria do delito quando efetuou o reconhecimento do réu. Que a motocicleta que foi restituída estava em estado íntegro. Que não conhecia o réu.

A testemunha de acusação, LEONARDO VIEIRA, em sede policial, informou que reside na Rua Luiz Gama, 547, próximo ao comércio de Assai de Eliete; que, o declarante conhece Eliete, e chegou a trabalhar com a mesma durante um período; que, na data de ontem, por volta das 21:00 hs o declarante estava em sua residência, quando ouviu um barulho que achou que fosse uma bomba; que, logo após o declarante ouviu um segundo estampido e resolveu ver o que estava acontecendo; que, o declarante ao sair de sua moradia deparou com um indivíduo desconhecido, pardo, magro, sem

capacete, barba ou bigode, de cabelo curto, o qual estava montado na motocicleta tentando dar um tranco; que, o declarante chegou a ver a cara do indivíduo o qual o encarou detidamente; que, a seguir o indivíduo desceu com o veículo sem capacete, pela contra mão de direção tomando rumo ignorado; que, o declarante não chegou a ver arma de fogo na mão do indivíduo, o qual a deve ter guardado; que, nisto o declarante foi até a casa de Eliete onde viu que a mesma estava caída no chão, e Renata gritava que haviam atirado na mesma; que, o declarante e o genro de Eliete, Emerson foram no veículo do mesmo até o PSM local, mas o declarante percebeu que a mesma estava morrendo; que, o declarante relatou o que viu a este signatário no local dos fatos e se colocou a disposição para prestar os esclarecimentos necessários; que, nesta tarde o declarante foi informado que deveria vir a Delegacia de Polícia pois uma pessoa suspeita de praticar o delito havia sido detida; que, o declarante veio até esta DelPol, onde em sala improvisada, reconheceu dentre quatro pessoas, a que ostentava o número 2, identificado como DAVID BENEDITO GONÇALVES DO ROSÁRIO como a pessoa que visualizou na motocicleta subtraída conforme acima relatado; que, o declarante conhece de vistas os irmãos DOUGLAS e GUIA, mas não tem relação de amizade com os mesmos; que, o declarante já teve passagem pela Polícia quando de menor mas nada deve a Justiça.

Em juízo, relatou que estava em sua residência, quando ouviu um barulho. Que, logo após ouviu um segundo estampido e resolveu ver o que estava acontecendo. Que ao sair de sua moradia deparou com um indivíduo, o qual estava montado na motocicleta tentando dar um "tranco". Que, chegou a ver a cara do indivíduo o qual o encarou detidamente. Que, a seguir o indivíduo desceu com o veículo sem capacete, pela contra mão de direção tomando rumo ignorado. Que, nisto foi até a casa de Eliete onde viu que a mesma estava caída no chão, e Renata gritava que haviam atirado na mesma. Que nunca tinha visto o réu. Que, após os fatos efetuou o reconhecimento do réu. Que quando foi efetuar o reconhecimento, o réu foi apresentado juntamente com outros indivíduos. Que não teve dúvidas que o autor do delito era o réu David.

A testemunha de acusação, Policial Militar, DIEGO LIMA PONTES DE ARAÚJO, em sede policial, declarou que após denúncia direto com a equipe, os Policiais tomaram conhecimento de que um indivíduo magro e loiro, havia deixado uma motocicleta em uma mata existente no local dos fatos. Em diligência pelo local, os Policiais localizaram o referido veículo, uma YAMAHA/YBR ROXA, placa DHI4F02. Após a localização, os Policiais deram início á buscas por possíveis objetos /entorpecentes, de interesse policial. Uma mochila preta foi localizada nas imediações, sendo que dentro desta havia uma calça de moletom preta com faixa estampada nas laterais, uma blusa de moletom branca toda estampada, uma faca de cozinha e a chave da moto ora localizada. Um pouco mais adiante, mas no mesmo perímetro, os Policiais ao perceberam a terra remexida próximo a uma árvore e escavaram, localizando dentro de um saco plástico 707 (850g) ependorf substância aparentando ser COCAÍNA, 05 (20g) saquinhos plástico também contendo uma substância aparentando ser COCAÍNA, 53 (8g) pedras aparentando ser CRACK e 216 (765g) porções de uma substância aparentando ser MACONHA. Em uma ladeira próxima, foi localizado um objeto envolto numa sacola plástica e ao verificarem o conteúdo, constataram se tratar de um REVÓLVER marca ROSSI, calibre 38, numeração suprimida, com três cartuchos íntegros e dois cartuchos deflagrados. Após pesquisa nos sistemas Policiais, verificou-se que a motocicleta localizada é produto de Roubo ocorrido no dia 07/10/2021 nesta urbe, sendo qualificada como uma das vítimas e proprietária da motocicleta, a SRA. RENATA BELLINI DOS SANTOS. O local foi preservado até a chegada da Perícia Técnica. O veículo, entorpecentes, arma e demais objetos foram trazidos até esta Unidade Policial para a elaboração da presente ocorrência. Após assinatura do Auto de Entrega, a motocicleta foi entregue à RENATA BELLINI DOS SANTOS.

Em juízo, declarou que após denúncia direto com a equipe, os Policiais tomaram conhecimento de que um indivíduo havia deixado uma motocicleta em uma mata nas proximidades do bairro Porto Belo. Que ao chegar no local para iniciar a averiguação não foi encontrada nenhum indivíduo na borda da mata. Que, diante disso, iniciou uma incursão dentro da mata. Que após andar alguns metros, localizou o referido veículo, uma YAMAHA/YBR ROXA, placa DHI4F02. Que também iniciou uma varredura nas imediações onde foi encontrada a motocicleta, resultando na apreensão

de uma mochila que no interior havia a chave da motocicleta, vestimentas e uma faca, sendo que ao lado encontrou entorpecentes e uma arma de fogo com duas munições deflagradas e uma intacta. Que todos os objetos permaneceram em isolamentos para devido fins periciais. Que a vítima Renata se deslocou até a delegacia para efetuar o reconhecimento do autor do delito e reconheceu David como sendo este. Que conhecia o réu devido a ocorrências anteriores envolvendo o mesmo. Que os objetos estavam escondidos de maneira idêntica, sendo perceptíveis rastros. Que o local onde encontraram os objetos e entorpecentes é frequentado por indivíduos do crime, no qual serve de esconderijo para os mesmos.

A testemunha de acusação, investigador, BRIZANO A. SILVA, em sede policial, reforçou seu depoimento prestado administrativamente, bem como corroborou com o depoimento de seu colega de farda.

Em juízo, relatou que no dia 07 de outubro de 2021 durante o período noturno recebeu a notícia que houve um roubo. Que o indivíduo teria feito um disparo em uma das vítimas. Que foi ao local para dar início as investigações. Que no local obteve imagens das câmeras de segurança e que por meio delas começou a trabalhar na busca do suspeito. Que chegou a informação que o indivíduo possuía a acunha "R15", então por já conhecer tal indivíduo facilitou o reconhecimento do suspeito do delito. Que recebeu a informação que a vítima Eliete ao ser levada ao pronto socorro local chegou lá sem vida em detrimento do ferimento causado pelo disparo. Que após denúncia direto com a equipe, os Policiais tomaram conhecimento de que um indivíduo magro e loiro, havia deixado uma motocicleta em uma mata existente no local dos fatos. Em diligência pelo local, os Policiais localizaram o referido veículo, uma YAMAHA/YBR ROXA, placa DHI4F02. Após a localização, os Policiais deram início à buscas por possíveis objetos /entorpecentes, de interesse policial. Uma mochila preta foi localizada nas imediações, sendo que dentro desta havia uma calça de moletom preta com faixa estampada nas laterais, uma blusa de moletom branca toda estampada, uma faca de cozinha e a chave da moto ora localizada. Um pouco mais adiante, mas no mesmo perímetro, os Policiais uma grande quantidade de entorpecentes e também um objeto envolto numa sacola plástica e ao verificarem o conteúdo, constataram se tratar de um REVÓLVER marca ROSSI, calibre 38, numeração suprimida, com três cartuchos íntegros e dois cartuchos deflagrados. Que, após a prisão do réu David, convidou a vítima Renata para que pudesse fazer o reconhecimento do autor do delito. Que a vítima Renata reconheceu sem sombra de dúvidas o indivíduo David como autor do delito. Que as imagens que flagraram o acontecido são provenientes do próprio estabelecimento comercial da vítima Eliete e também do laboratório ao lado do estabelecimento. Que o local onde encontraram os objetos e entorpecentes é frequentado por indivíduos do crime, no qual serve de esconderijo para os mesmos. Que outra pessoa além do réu poderia ter deixado os entorpecentes nesse local, porém que o fato que liga o réu aos entorpecentes é devido a prisão anterior por tráfico de drogas, na qual as drogas não foram localizadas, e também ao restante dos itens encontrados no mesmo local.

O réu DAVID BENEDITO GONÇALVES DO ROSÁRIO, em seu interrogatório em solo policial, respondeu que não sofreu agressão por parte dos policiais que o prenderam; que dispensa a presença de advogado; que ciente da acusação imputada, o interrogando deseja prevalecer-se do seu direito e manifestar-se apenas em juízo.

Em seu interrogatório em juízo, negou os fatos. Respondeu que é "olheiro" em atividades de traficância. Que a arma era sua. Que não tem nenhuma relação com o ocorrido.

Destarte, verifica-se que as provas orais e documentais coligidas aos autos não deixam dúvidas sobre a prática do fato descrito na denúncia. Os depoimentos colhidos em juízo corroboram com os demais elementos constantes nos autos.

E não se diga que o depoimento de policiais não merece credibilidade. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por policiais, civis ou militares, mesmo porque seria um contra-senso o Estado, que outrora os credencia para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chama à prestação de contas perante o Poder Judiciário, não mais lhes empreste a mesma credibilidade.

Nesse sentido, por sinal, a melhor jurisprudência:

"A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - HC 70.237 - Rel. Carlos Velloso - RTJ 157/94). "O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC 73.518- 5 - Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Por isso, força convir, os depoimentos dos policiais, no caso, merecem crédito e servem, perfeitamente, para supedâneo da prolação de sentença condenatória, depoimentos estes que, em juízo, harmônicos entre si, sintonizaram-se com os depoimentos prestados extrajudicialmente.

Convém mencionar que o delito de roubo é caracterizado pela subtração, ou seja, inversão da posse do bem, com ânimo de tê-la em definitivo para si ou para outrem, utilizando como meio de execução a violência ou grave ameaça.

Ressalte-se que os Tribunais Superiores adotam a teoria da amotio, segundo a qual o delito de roubo é crime material e instantâneo, caracterizando-se com a posse de fato da res furtiva, restando consumado ainda que o agente permaneça com o bem por curto espaço de tempo.

Nesse sentido:

"DIREITO PENAL. TIPICIDADE DA CONDUTA DESIGNADA COMO "ROUBO DE USO". É típica a conduta denominada "roubo de uso". De início, cabe esclarecer que o crime de roubo (art. 157 do CP) é um delito complexo que possui como objeto jurídico tanto o patrimônio como a integridade física e a liberdade do indivíduo. Importa assinalar, também, que o ânimo de apossamento - elementar do crime de roubo - não implica, tão somente, o aspecto de definitividade, pois se apossar de algo é ato de tomar posse, de dominar ou de assenhorar-se do bem subtraído, que pode trazer o intento de ter o bem para si, de entregar para outrem ou apenas de utilizá-lo por determinado período. Se assim não fosse, todos os acusados de delito de roubo, após a prisão, poderiam afirmar que não pretendiam ter a posse definitiva dos bens subtraídos para tornar a conduta atípica. Ressalte-se, ainda, que o STF e o STJ, no que se refere à consumação do crime de roubo, adotam a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual se considera consumado o delito no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima. Ademais, a grave ameaça ou a violência empregada para a realização do ato criminoso não se compatibilizam com a intenção de restituição, razão pela qual não é possível reconhecer a atipicidade do delito "roubo de uso". (REsp 1.323.275-GO, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 24/04/2014)

Acresça-se a isso que, em se tratando de roubo qualificado pela morte, o mesmo é caracterizado como crime qualificado pelo resultado, sendo que o resultado agravador emana da violência. O emprego da violência deve ser doloso, sendo que o resultado pode ser doloso ou culposos.

Assim, para que o latrocínio seja configurado, resta-se necessário o preenchimento de requisitos, quais sejam, a violência deve ser empregada durante o roubo e deve haver relação de causalidade entre a subtração e a morte. Isso é, a morte deve ocorrer no contexto e em razão do roubo.

É neste sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00000281620178260052 SP 0000028-16.2017.8.26.0052, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 26/09/2019, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/09/2019; TJ-SP - EI: 00013411420148260635 SP 0001341-14.2014.8.26.0635, Relator: Camargo Aranha Filho, Data de Julgamento: 21/05/2019, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/05/2019; TJ-SP - APR: 00225394820168260050 SP 0022539-48.2016.8.26.0050, Relator: Alcides Malossi Junior,

Data de Julgamento: 26/11/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/11/2020.

Ademais, nos termos da Súmula 610 do Supremo Tribunal Federal, há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. Portanto, não há que se falar em desclassificação, uma vez que o dolo do agente foi de praticar o crime previsto no art. 157, §3º, II, do CP.

Desta feita, a palavra da vítima toma especial contorno, ainda mais quando escorada em descrição detalhada da conduta delituosa. Ainda nesse plano de análise, merece destaque o reconhecimento pessoal do acusado DAVID realizado pela vítima (fls. 15,17,19), assim como em seu depoimento, em solo policial, onde reconheceu "sem sombra de dúvidas, a pessoa de DAVID BENEDITO GONÇALVES ROSÁRIO, como a pessoa que mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo subtraiu sua motocicleta da marca Yamaha, modelo YBR, de placa DHI 4F02 de Porto Ferreira, e efetuou dois disparos de arma de fogo, um destes que atingiu sua patroa ELIETE APARECIDA ROSINI FERRACIN MUNHOZ." que não só o indicou como o autor dos fatos, como também descreveu em detalhes as características físicas do acusado.

Via de consequência, inexistem quaisquer dúvidas sobre a materialidade e a autoria do delito, sendo adequada a capitulação empreendida em sede de denúncia.

A grave ameaça, indispensável à caracterização do delito de roubo, restou satisfatoriamente demonstrada nos autos. Com efeito, constatou-se pelo depoimento da vítima "que no instante que montou em sua motocicleta para ir embora, uma rapaz desconhecido, exibindo uma arma de fogo tipo revólver de cor preta, aproximou-se anunciando que tratava-se de um assalto, sendo certo que o indivíduo queria roubar sua motocicleta; que de imediato, no reflexo, acabou resistindo em sair da motocicleta, tendo o rapaz, efetuado um disparo para o alto; que ato contínuo desceu da motocicleta, sendo empurrado pelo indivíduo, sendo que, após isso ele efetuou outro disparo na direção da porta do Estabelecimento Comercial; que o disparou acertou o pescoço de sua patroa ELIETE APARECIDA FERRACIN MUNHOZ, a qual veio a óbito ali mesmo no local;" (fl. 13/14) para ameaçar a vítima, configurando a grava ameaça.

Quanto ao delito do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06:

Ademais, a jurisprudência é pacífica acerca da desnecessidade que o infrator seja colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida para a configuração da traficância. Assim "(...) a classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (TJSP Apelação Criminal nº 20.239, Rel. Geraldo Gomes, RT 584/347).

Incabível a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, ante a quantidade de drogas e o encontro de balança de precisão e envolvimento prévio do denunciado com a prática de tráfico ilícito de drogas. A condição de usuário não exclui, necessariamente, a prática do crime de tráfico de drogas. Pelo contrário, a experiência mostra que é comum a traficância entre dependentes e usuários justamente para viabilizar o sustento do consumo próprio, sendo inviável o afastamento do dolo ou desclassificação do delito para outro de menor gravidade (TJSP. Apelação Criminal nº 1.167.864.3. Rel. Juvenal Duarte.

Quinta Câmara Criminal, J. 15.05.08).

Destaca-se que o crime de tráfico de entorpecente é de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a prática de qualquer um dos núcleos verbais do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, independentemente da concretização ou não da entrega ao destinatário, pelo que as simples condutas do réu, consistente em "ter em depósito" e "trazer consigo" a substância entorpecente, já são suficientes para caracterização do delito:

O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente (RT 776/663); Sendo assim, a quantidade de drogas apreendidas, e os depoimentos seguros prestados

pelos agentes de segurança, levam à certeza de que o réu traficava drogas, impondo-se a condenação nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Portanto, comprovadas estão a materialidade e autoria delitiva.

Por fim, o acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o réu praticou a conduta delitiva descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo crime praticado.

Passo a dosar a pena

I - PARA O CRIME DE ROUBO PREVISTO NO ARTIGO 157, § 3º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL: Na primeira fase, analisadas as diretrizes do art. 59, do CP, verifica-se que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie delitiva. É possuidor de maus antecedentes. Não há elementos nos autos sobre a personalidade do réu e sua conduta social. Os motivos e as consequências do crime não destoam do esperado em crimes desta natureza. As circunstâncias não lhe são desfavoráveis, e as vítimas em nada concorreram para o crime. Assim, fixa-se a pena base em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, mas reconheço a agravante da reincidência (consta da FA de fls. 141/149), ficando a pena intermediária em 24 (vinte e quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena fixada em 24 (vinte e quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa.

II - PARA O CRIME DE TRÁFICO PREVISTO NO ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI Nº 11.343/06: Na primeira fase, observando-se os elementos previstos no artigo 59, do CP, e artigo 42, da Lei n. 11.343/06, verifica-se que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie delitiva. É possuidor de maus antecedentes. Não há elementos nos autos sobre a personalidade do réu e sua conduta social. Os motivos e as consequências do crime não destoam do esperado em crimes desta natureza. As circunstâncias não lhe são favoráveis ante a quantidade de drogas apreendidas "Entorpecentes Apreendidos: Tipo de Tóxico Cocaína, Quantidade 850 Gramas, Tipo de Acondicionamento Supositorio, Quantidade Acondicionamento 707, Observação LACRE: 26510, Tipo de Tóxico Cocaína, Quantidade 20 Gramas, Tipo de Acondicionamento Outros, Quantidade Acondicionamento 5, Observação LACRE: 26512, Tipo de Tóxico Crack, Quantidade 8 Gramas, Tipo de Acondicionamento Pedra, Quantidade Acondicionamento 53, Observação LACRE: 26513" (fl. 35).

Quanto à fixação da pena-base, é certo que, em muitos casos - aliás, na grande maioria - um critério matemático parece ser suficiente para alcançar a pena justa. Entretanto, há casos em que a intensidade da reprovação desta ou daquela circunstância judicial torna tal critério desarrazoado e descolado da realidade. Entendo que este é um destes casos.

Com fundamento no princípio da individualização da pena, forte no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição da República, observo que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido, em ações penais originárias, que as circunstâncias devem ser sopesadas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime. Por exemplo, na APn 327/RR (rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18/12/2018, DJe 19/12/2018).

Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também é possível encontrar decisões no sentido de que não há se falar em tarifação de aumentos em tabelas predeterminadas. Já se decidiu que "não se há falar em tabelamento das reprimendas, nem mesmo em institucionalização da pena mínima" (TJSP, Apelação n. 0000142-53.2017.8.26.0472, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Costabile e Solimene, j. 23.08.2018) e que "que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base" (AP 996/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 29/05/2018, DJe 08/02/2019).



Ora, segundo o procedimento tradicional que valora cada circunstância judicial com um aumento de 1/6 ou 1/8, a reprimenda máxima para o fato criminoso ocorrerá somente quando estiverem presentes todas as circunstâncias negativas, pouco importando sua gravidade, ao passo em que um fato criminoso que tenha uma circunstância judicial negativa, mas presente com grande reprovabilidade, sofrerá um aumento mínimo.

Evidente que isto é uma má interpretação do sistema de imposição de penas estabelecido pela Reforma do Código Penal de 1984 e um descumprimento da Constituição da República, que exige a individualização da pena e demanda uma valoração da gravidade concreta das circunstâncias. Afinal, o art. 59 do Código Penal exige que a fixação da pena atenda à finalidade de reprobção e prevenção do crime, o que também não se alcança com tabelamentos.

Deste modo, o juiz deve fixar o aumento da pena-base não somente a partir do número de circunstâncias judiciais negativas, mas de acordo com a intensidade concreta das circunstâncias, a fim de evitar indesejáveis automatismos judiciais.

Com tais ponderações, fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1000 (mil) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, mas reconheço a agravante da reincidência (consta da FA de fls. 141/149), ficando a pena intermediária em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 1.116 (mil cento e dezesseis) dias-multa. Na terceira fase, não há como se aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da lei n. 11.343/06. Com efeito, de acordo com os C. STJ e STF, são requisitos, cumulativos, para aplicação da referida causa de diminuição: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa.

Nesse sentido:

(...) III - Para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, hipótese não caracterizada no caso em concreto, ante a comprovação da reincidência (precedentes). (...) Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC 287.687/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015)

(...) 4. A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar pelo menos um dos critérios, que são autônomos, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. (...). 5. Ordem denegada. (STJ, HC 127221, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015)

Inviável a aplicação da redução da pena, haja vista que o réu se dedica a atividades criminosas. Além disso, os policiais afirmaram ser de conhecimento que, para poder realizar o tráfico na região, necessário que esteja integrado com o grupo dominante, o que reforça sua integração a atividades criminosas.

Sendo assim, a pena total, levando-se em conta o concurso material de infrações, previsto pelo artigo 69 do Código Penal, as penas serão aplicadas cumulativamente, fixando a pena definitiva em 36 (trinta e seis) anos 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 1179 (um mil cento e setenta e nove) dias-multa. Fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena, na forma do art. 33, §2º, "a" e seu § 3º, ambos do Código Penal, ante a quantidade de pena aplicada.

A substituição da pena privativa de liberdade não é possível diante da quantidade de pena e em razão de o crime ter sido cometido mediante violência e grave ameaça. Fixo o valor do dia multa no mínimo legal, diante da capacidade econômica do réu.

Ante o exposto, com fulcro no art. 387 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR, DAVID BENEDITO GONÇALVES DO ROSÁRIO, à pena privativa de liberdade de 36 (trinta e seis) anos 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, regime inicial fechado, e pagamento de 1179 (um mil cento e setenta e nove) dias-multa, dando-o como incurso nas sanções do artigo 157, § 3º, inciso II do Código Penal e no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em concurso

material de infrações.

Considerando que o réu respondeu ao processo preso, e que com a sentença condenatória entendeu-se pela efetiva prática do crime, irrazoável que possam recorrer em liberdade, motivo pelo qual mantenho a prisão do réu, pela permanência das circunstâncias do art. 312 do CPP e atendimento aos requisitos do art. 313, I do mesmo código processual, conforme decisões de fls.137/138. Recomende-se o réu no lugar em que se encontra.

Deixo de fixar a indenização à vítima, uma vez que não houve pedido nesse sentido, em homenagem aos princípios do contraditório e da congruência.

Comuniquem-se as vítimas sobre esta decisão, nos termos do art. 201, § 2º, do CPP. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa uma vez que nessa oportunidade concedo-lhe o benefício da gratuidade da justiça.

Expeça-se ou adite-se a guia de execução, encaminhando-se à Vara das Execuções Criminais competente.

Após o trânsito em julgado:

Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária nos termos do art. 686, do CPP;

Oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no art. 15, III, da CF;

Oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre condenação dos réus.

Expeça-se guia de execução penal.

Fica desde já os réus intimados a pagar os dias multa, em 5 dias a contar do trânsito em julgado.

Caso o E. Tribunal de Justiça mantenha esta sentença absolutória ou condenatória, cumpra-se o v. acórdão e o integralmente o acima disposto, arquivando-se.

Caso esta sentença seja reformada, cumpra-se o v. acórdão. E, comunique-se o trânsito em julgado ao e. Tribunal de Justiça, se for o caso.

Aguarde-se por 120 dias o julgamento do "habeas corpus", se for o caso.

P.I.C.

Porto Ferreira, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA